

1525927-54.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. O réu e um menor de idade estavam em uma viela e no final dessa viela tem uma escada. Observaram de longe a movimentação característica de venda do ilícito. Hoje mesmo por coincidência foram ao mesmo local na mesma viela e pegaram dois indivíduos no mesmo local no tráfico de drogas. No dia da ocorrência as drogas estavam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525927-54.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525927-54.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291536/2021 - 49º D.P. SAO MATEUS, 21027653 - 49º D.P. SAO MATEUS, 6992/21/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2291536 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO CARLOS DA SILVA JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

MARCELO CARLOS DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de outubro de 2021, por volta de 11h00, na Rua Ruanda, 10, Aricanduva, nesta capital, envolvendo o adolescente Carlos Alberto de Andrade Rocha, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 35 invólucros de maconha (61,4 gramas) e 83 invólucros de cocaína (27,1 gramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 106,00 (cento e seis reais) em espécie, provenientes da mercancia

ilícita de entorpecentes.

Consta da denúncia que, segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pela região, conhecida pela ocorrência de tráfico de entorpecentes, quando avistaram o denunciado e o adolescente em atitudes típicas de mercancia ilícita de drogas, vez que havia movimentação estranha de transeuntes no local. Diante da fundada suspeita, deliberaram abordá-los.

É da inicial que, na abordagem, os policiais lograram encontrar duas bolsas ao lado dos increpados, no interior das quais foram localizadas 35 porções de maconha, 83 porções de substância semelhante à cocaína, além de R\$ 106,00 em espécie (auto de exibição/apreensão – fls. 14/15).

Narra a denúncia que, indagados, informalmente, ambos confessaram a mercancia ilícita no local do fato.

Extraí-se da exordial que, em seguida, os objetos foram apreendidos, sendo o denunciado juntamente com o adolescente encaminhados à Delegacia de Polícia, onde MARCELO invocou o direito constitucional de se pronunciar em juízo (Termos de Interrogatório à fls. 10).

Relata a inicial que o laudo de constatação de fls. 17/20 restou positivo para 61,4 gramas de tetrahydrocannabinol – THC e 27,1 gramas de cocaína sólida particulada.

Por fim, é da denúncia que as circunstâncias que envolveram a prisão, assim como a quantidade e forma de acondicionamento das drogas evidenciam que as substâncias se destinavam ao tráfico ilícito de drogas.

Por decisão exarada no dia 26 de outubro de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 35/41).

O réu foi citado (fl. 93).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e a denúncia foi recebida.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais civis e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu, em síntese, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, menor de 21 anos, não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; c) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, pois não há provas de que o réu tenha envolvido o adolescente Carlos Alberto na suposta traficância, ressaltando-se que o adolescente sequer foi ouvido em juízo para que fosse possível averiguar suas condições pessoais ou mesmo as circunstâncias em que teria em tese participado do crime; d) a outorga de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; e) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do art. 33, caput c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

A peça acusatória está amparada em prova de materialidade: Auto de Prisão em

Flagrante (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência (fls. 11/13), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15), Laudo de Constatação (fls. 17/20), cuja conclusão foi resultado positivo para as substâncias cocaína (resultado dos Itens 1 e 2) e tetrahidrocannabinol (resultado dos Itens 3 e 4), Laudo Químico-Toxicológico definitivo (fls. 98/100), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas diante da prova oral colhida em juízo.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Evandro de Oliveira, policial civil, narrou, em síntese, que lembra do réu presente em audiência. Estavam em diligências com viatura descaracterizada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. O réu e um menor de idade estavam em uma viela e no final dessa viela tem uma escada. Observaram de longe a movimentação característica de venda do ilícito. Hoje mesmo por coincidência foram ao mesmo local na mesma viela e pegaram dois indivíduos no mesmo local no tráfico de drogas. No dia da ocorrência as drogas estavam dentro de uma bolsa ao lado deles, ao lado da escada. Tinha cocaína e maconha. Invólucros individuais, acha que tinha um pouco mais de 100 e aproximadamente cento e poucos reais. A bolsa contendo drogas e dinheiro estava no chão, ao lado do réu e do menor. Viram duas pessoas, primeiro uma e depois a outra, se aproximando do réu e do adolescente.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Rubert Patrick de Assis Bagolin, policial civil, extraíndo-se de seu depoimento, em suma, que lembra do réu. O local é uma viela sem saída. O depoente e o parceiro viram que o réu e o menor estavam no fundo da viela e ao abordá-los ao lado tinha drogas e dinheiro trocado em uma bolsa ou algo do gênero. Tinha maconha e cocaína. Não se recorda a quantidade de drogas. O réu e o adolescente estavam juntos no momento da abordagem. Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Narrou, em síntese, que está com 20 anos de idade. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Parou de estudar porque começou a trabalhar. Mora com a os pais e dois irmãos. Estava trabalhando como tatuador e trabalhava com o vizinho com funilaria. Os policiais estão mentindo. Tinha ido ao local comprar uma maconha. Tem certeza que foi forjado por suas tatuagens. Os policiais falaram que as tatuagens eram de "bandido". Conhece o adolescente de vista. Pediu uma maconha ao adolescente. Quem estava traficando no dia era o adolescente. O local é cerca de 4, 5 minutos da casa do interrogando. Nunca tinha visto os policiais antes.

Ocorre que, diante de todo conjunto probatório, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

A finalidade de narcotraficância foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha); b) pela considerável quantidade de drogas apreendidas, incompatível com a condição de mero usuário (27,1g de cocaína e 61,4g de maconha); c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas, prontas para comercialização; d) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto a apreensão da quantidade de entorpecentes encontrados com o réu, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram

apreendidas para o fim de comercializá-las, registrando-se a natureza dos entorpecentes, sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

Dispõe o aludido dispositivo que: "Art. 40 - As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação". (grifos nossos).

Restou demonstrado que a apreensão dos entorpecentes que estavam em poder do réu envolvia o adolescente Carlos Alberto de Andrade Rocha, com 17 anos de idade, sendo aplicável a mencionada causa de aumento de pena.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal

Em primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, conforme folha de antecedentes as fls. 29/30 e certidões as fls. 33/34 e 77/78, não se olvidando o disposto na súmula 444 do Colendo STJ. No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da menoridade (réu tinha 20 anos na data dos fatos), no entanto, deixo de reduzir a pena, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, aumento a pena de um sexto, culminando com a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ainda em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, autorizam a redução de 2/3 (dois terços) da pena fixada, culminando com a pena final de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa, que ante a ausência de outras circunstâncias, torno pena definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade, a menoridade e a pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, menor de 21 anos de idade e sem ligação comprovada com organização criminosa.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal,

bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)." (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo.

Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado.

Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade.

Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos)

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o réu MARCELO CARLOS DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 194 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, não se justifica a manutenção da prisão preventiva, devendo ser facultado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº. 11.343/06, decreto o perdimento do valor retratado em fls. 52 (R\$ 106,00) e bolsas apreendidas (fls. 14) em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento após o trânsito em julgado.

Determino a destruição das drogas apreendidas (art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA